

1500990-88.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes.

No caso, não ficou suficientemente provado que estavam associados para fins de tráfico de drogas. O tipo penal exige "o animus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500990-88.2020.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500990-88.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179539/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 12578817 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 431/20/571 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 2179539 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANAINA APARECIDA NEVES QUEIROZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, JANAINA APARECIDA NEVES QUEIROZ e WANDERSON DA CRUZ BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em regime de concurso material, c/c art. 29 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, em data não esclarecida, mas no ano de 2020, nesta cidade, os acusados, em conluio e unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada de crimes de tráfico ilícito de drogas e também porque no dia 22 de julho de 2020, no período da tarde, na Rua Arlei de Souza, 1157, nesta

cidade e comarca, os acusados, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam e tinham em depósito, para fins de comercialização a terceiros, 1.856 porções de cocaína, pesando 614,590 gramas, 08 porções de cocaína, pesando 354,290 gramas, e 03 tijolos de cocaína, pesando 2.985,390 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.

Narra a denúncia que os acusados adquiriam grandes quantidades de drogas, ainda em estado bruto, preparavam e embalavam os entorpecentes, em pequenas porções, para venda no varejo, a usuários. Conforme apurado, policiais, há dois meses, vinham investigando um indivíduo que forneceria drogas para o Bairro João Paulo II, o qual fazia uso de um veículo HB20 branco e teria como local para armazenamento e embalagem um imóvel no bairro Fraternidade. O indivíduo foi identificado como sendo o acusado Marcos, e que o veículo ostentava a placa FMN-8820, o qual tinha como logística se dirigir até o imóvel, onde deixava a acusada Janaína e o acusado Wanderson, vulgo "Pará", saindo em seguida, retornando tempos depois para buscá-los. Os policiais chegaram então ao potencial local que era utilizado por Marcos, sito a Rua Arlei de Souza, nº 1157, Bairro Fraternidade, nesta cidade. Na data dos fatos os policiais ficaram observando o local e viram quando, por volta das 08 horas, o veículo ali adentrou com três pessoas, sendo Marcos e um casal, identificados como sendo os acusados Janaína e Wanderson. Passado algum tempo Marcos foi embora, sendo acompanhado. Uma equipe permaneceu no imóvel e Marcos retornou para sua residência. Após várias horas Marcos saiu e parou no hospital no bairro Boa Vista, quando foi abordado. Indagado, Marcos acabou por confessar que usava realmente referido imóvel para guardar e embalar drogas, sendo que em seu veículo estava o controle remoto do portão e a chave, tipo tetra. Marcos disse ainda que tinha no local 03 peças de cocaína. No imóvel em tela, o portão foi aberto por Marcos, com o controle, tendo dito que a porta estaria aberta, franqueando a entrada aos policiais, sendo surpreendidos embalando drogas os acusados já identificados como Janaína e "Pará" (Wanderson). Em revista pelo local foram encontradas as três peças faladas por Marcos, três tijolos de cocaína e grande quantidade de porções também da mesma droga (1856 porções individualmente embaladas e prontas para serem distribuídas). Ainda no local foram encontradas balanças digitais, isqueiros utilizados para embalar as porções, rolos e sacos plásticos, os quais eram cortados em pedaços para embalagem, além de mais drogas à granel (08 sacos, sendo 04 médios e 04 pequenos) e outros petrechos (tesouras, prato e colheres com resquícios de drogas). Narra que as porções de cocaína eram embaladas individualmente e a seguir, em bolsas contendo 05 "bolsinhas", com 14 porções cada, as quais eram distribuídas aos vendedores finais. Cada porção era vendida a R\$ 20,00. Foram apreendidos também com cada um dos acusados, um aparelho de telefone celular. Narra que os acusados compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas e realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente.

Notificados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 471/477, 517/519 e 578/583).

Recebida a denúncia (fls. 687/690), os réus foram citados (fls. 727, 729 e 731).

Na audiência de instrução, depois de ouvidas as testemunhas, foi declinada a competência para a 4ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 757/764).

O Juízo da 4ª Vara Criminal determinou a devolução dos autos (fls. 811/812) e foi suscitado o conflito negativo de competência (fls. 832/837). O Tribunal de Justiça conheceu do conflito e declarou a competência desta Vara para julgar o presente feito (fls. 928/936).

Após juntada de provas requeridas pelas partes, os acusados foram interrogados (fls. 1132/1140).

A instrução foi encerrada e em alegações finais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa do corréu Marcos Vinícius alegou, em preliminar, nulidade das provas por busca infundada, invasão de domicílio e continência e, no mérito, absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado. A Defesa do corréu Wanderson pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a absolvição do delito do artigo 35 da Lei de Drogas por falta de provas. Por sua vez, a Defesa da corré Janaína alegou incompetência, invasão de domicílio e falso testemunho dos policiais civis e no mérito, em resumo, requereu a absolvição por falta de provas (fls. 1144/1155, 1157/1186, 1211/1216 e 1217/1229).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiro analiso as preliminares arguidas.

Não há nenhuma ilicitude na conduta dos policiais, pois havia um estado de flagrância. Havia investigação prévia, com interceptação telefônica autorizada judicialmente e, após campana no imóvel, está justificado o ingresso na residência.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas é permanente, logo, possível o ingresso em residência, quando existirem indícios da prática de crime. Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito. Como visto, a entrada na residência estava amparada em investigações pretéritas e campana. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 05/11/2015 o Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e

penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (grifo meu).

Se não bastasse, o acusado MARCOS, no auto de prisão em flagrante, devidamente assistido por advogado, foi categórico que autorizou a entrada dos policiais no imóvel. É certo que as câmeras de segurança do local mostram os policiais chegando em veículo preto e adentrando no imóvel primeiro que o acusado, mas este já tinha sido abordado e estava no veículo branco, que vinha atrás. Consta no laudo pericial:

Imagem nº 07: Três veículos se aproximam do imóvel enquanto o portão da garagem se abre (23-07-2020 14:22:24)

Imagem nº 08: Veículo de cor preta para defronte à garagem (23 -07-2020 14:22:26)

Imagem nº 09: Quatro indivíduos portando armas e distintivos saem do veículo preto e ingressam pelo portão da garagem (23-07-2020 14:22:30)

Imagem nº 10: Veículo de cor branca se aproxima da garagem. O outro veículo de branca (FMN-8820) estaciona na rua Sebastião Petenelli, próximo à esquina (23-07-2020 14:22:32)

Imagem nº 11: Veículo de cor branca estaciona defronte ao portão da garagem e indivíduo algemado trajando camiseta verde e boné preto sai pela porta posterior esquerda (23-07-2020 14:26:32) – fls. 1084/1086.

Vê-se, portanto, que os policiais, autorizados pelo acusado, adentram primeiro no imóvel para não frustrar a diligência.

Assim sendo, não há que se falar em invasão de domicílio e prova ilícita.

Ainda sobre a revista pessoal é necessário salientar que é permitida (art. 240 do Código de Processo Penal) e, neste caso, havia fundada suspeita. Ora, havia investigação prévia e como o acusado Marcos havia adentrado e saído de imóvel onde havia suspeita de haver a prática da traficância justificada está a abordagem policial, com revista pessoal e no veículo.

A questão da competência está superada com o V. Acórdão do Tribunal de Justiça que declarou em sede de conflito negativo a competência desta Vara para processar e julgar a presente ação penal (fls. 928/936).

Ficou assentado no V. Acórdão:

"Nesse contexto, ao que se extrai dos autos, não se vislumbra um entrelaçamento dos fatos apurados em ambas as demandas a ponto de se estabelecer a reunião dos feitos, recaindo cada qual à apuração de crimes supostamente praticados em circunstâncias fáticas desvinculadas entre si.

Como se nota, muito embora as acusações tenham se amparado em indícios constatados na interceptação telefônica deferida pelo Juiz suscitado, não há conexão entre os crimes.

Em verdade, os autos tratam de imputações decorrentes do encontro fortuito de provas, não importando incidência do artigo 83 do Código de Processo Penal" (grifo meu).

Assim sendo, também não há que se falar em continência, nem conexão.

Quanto ao mérito, no auto de prisão em flagrante o acusado MARCOS, acompanhado de advogado, afirmou ser usuário de drogas há cerca de um ano e meio, sendo que faz uso de cocaína e "ecstasy". É portador de HIV e na data dos fatos passou pelo médico, sendo que, ao sair do consultório, foi abordado por policiais. Fazia uso do veículo HB20, branco, o qual é de propriedade de sua ex-amásia e pegou emprestado somente com a finalidade de ir até referido médico e nunca o usou para traficar

drogas. Logo na abordagem os Policiais lhe disseram: "caiu a casa, vamos lá no seu mocó que lá tem droga", ficando sem entender o que estava acontecendo. Ao ser cientificado que o tal "mocó" seria na Rua Arlei de Souza, 1157, Fraternidade, aí se recordou que na verdade o local é de sua ex-amásia de nome "Simone Regina". Como o local precisava de reparos, estava com as chaves do imóvel. Indagado sobre drogas no local, confirmou que tinha três peças de "cocaína" escondidas naquela casa, uma vez que está desempregado e resolveu comprar drogas, já batizadas, para fracioná-las e revendê-las. Comprou as drogas alguns dias antes dos fatos, na cidade de Ribeirão Preto/SP, onde adquiriu de um desconhecido pela quantia de R\$20.000,00, sendo que iria pagar ao vendedor conforme fosse vendendo. Foram até o endereço mencionado e ao chegarem encontraram seus conhecidos "Janaina" e "Wanderson Pará", os quais conhece há 4 ou 5 meses. Janaina estava lá para fazer faxina e Wanderson para fazer reparos na pintura. Tinha escondido na cozinha as 03 peças de cocaína, não tendo mencionado a nenhum deles que havia drogas no local. Autorizou a entrada dos policiais no imóvel, os quais acabaram por encontrar muitas porções de cocaína, já embaladas por Janaina e Wanderson, querendo deixar consignado que não autorizou ninguém a mexer na sua droga. No local foram encontradas também petrechos utilizados para fracionamento e embalagem de drogas, tais como balanças, tesouras, plásticos, isqueiros, etc. Tais objetos lhe pertencem, pois, como já disse, iria fracionar em porções. Quis deixar consignado que Janaina e "Pará" não sabiam e não estavam autorizados a mexer nas suas drogas. Informou que a residência é monitorada por câmeras, sendo que os policiais fizeram a apreensão do seu DVR para verificação das imagens. Em Juízo o acusado apresentou nova versão, dizendo que foi procurado por Wanderson, pessoa que já conhecia e mantinha amizade, o qual lhe propôs a quantia de R\$500,00 para usar sua casa para manusear entorpecentes. Esclareceu que enfrentava dificuldades, com quadro de depressão e tinha duas filhas, acabando por aceitar a oferta, emprestando sua casa para Wanderson e outra pessoa manusear drogas, sem saber a quantidade. Foi a primeira vez que emprestou o imóvel para tal fim. Deixou o imóvel e se dirigiu ao médico, mas logo que saiu da consulta já foi abordado pelos policiais, sendo que voltaram ao imóvel e todos foram abordados. Não conhecia Janaina. Policiais usaram o controle que estava em seu veículo para abrir o portão. Não tinha conhecimento da quantidade de drogas que estava no imóvel. Na delegacia acabou assumindo a propriedade da droga porque era primário e Wanderson lhe pediu, mas sequer viu o que foi escrito.

Na fase policial a acusada JANAÍNA, também acompanhada de defensor, afirmou que estava perto do Bosque Municipal quando então passou pelo local seu conhecido Marcos, dirigindo um HB20, branco, onde lhe ofereceu carona. Marcos estava acompanhado de outro conhecido, vulgo "Pará". Foi então combinado entre eles que iriam até uma residência no bairro Fraternidade, onde ela ficaria na companhia de "Pará", sendo que Marcos iria ao médico e depois retornaria ao local. Inicialmente parou no imóvel para fazer faxina para Marcos. Estava sentada entre a sala e a cozinha, conversando com Pará, quando lá chegaram os policiais e Marcos. Os policiais passaram a revistar o imóvel e encontraram grande quantidade de porções de cocaína já embaladas, bem como à granel, e tijolos e outros petrechos utilizados no fracionamento e embalagem de drogas (balanças, sacos plásticos, tesouras, pratos, etc...). Não sabia que havia drogas na casa, acreditando também que Pará não tinha conhecimento. Em Juízo novamente negou a prática dos crimes que lhe são imputados, aduzindo que foi convidada por Wanderson para fazer faxina no imóvel, sendo levada até o local por Wanderson e Marcos, mas logo depois foram abordados por policiais. Conhecia Marcos apenas de vista, pois moravam no mesmo bairro. Estava no imóvel há pouco tempo. Indicou que trabalha na cozinha de uma escola municipal, mas em razão da pandemia a carga horária diminuiu, bem como o salário, sendo que fazia faculdade e precisava aumentar a renda para sustentar os dois filhos, razão pela qual passou a fazer "bicos".

O acusado WANDERSON permaneceu em silêncio na fase policial e em Juízo assumiu a propriedade de toda a droga, indicando que precisava de um local para fracionar o entorpecente, sendo que pediu para que Marcos lhe emprestasse a casa para tanto,

oferecendo-lhe a quantia de R\$500,00 pelo empréstimo do imóvel. Chamou Janaína para ajudá-lo a fracionar e embalar a droga, sendo que também lhe daria dinheiro pelo serviço. Foi a primeira vez que usou o imóvel. Buscou outro imóvel porque tem antecedentes criminais e queria proteger seus familiares.

No auto de prisão em flagrante o policial Wilson Cestonário Larrubia afirmou que há dois meses investigava um indivíduo que fornecia drogas no bairro João Paulo II, o qual fazia uso de um veículo HB-20, branco, e teria como local para armazenamento e embalagem um imóvel no bairro Fraternidade. O indivíduo foi identificado como sendo o acusado Marcos e o veículo ostentava a placa FMN-8820, o qual tinha como logística se dirigir até o imóvel, onde deixava Janaína e "Pará", saindo em seguida, retornando tempos depois para buscá-los. Chegou-se então ao potencial local que seria utilizado por Marcos, sito na Rua Arlei de Souza, 1157, bairro Fraternidade, nesta cidade. Na data dos fatos ficou observando o local e viu quando, por volta das 08 horas, o veículo ali adentrou com três pessoas, Marcos e um casal, Janaína e Wanderson, vulgo "Pará". Após um tempo Marcos foi embora, sendo acompanhado. Uma equipe permaneceu no imóvel e Marcos retornou para sua residência. Após várias horas Marcos saiu e parou no hospital no bairro Boa Vista, quando foi abordado. Indagado, Marcos acabou por confessar que usava realmente o imóvel para guardar e embalar drogas, sendo que em seu veículo estava o controle remoto do portão e a chave. Marcos disse ainda que tinha no local três peças de cocaína. No imóvel o portão foi aberto por Marcos com o controle, tendo dito que a porta estaria aberta, franqueando a entrada dos policiais, sendo surpreendidos embalando drogas os acusados Janaína e Wanderson. Durante as buscas encontraram os três tijolos de cocaína e grande quantidade de porções também da mesma droga (1856 porções individualmente embaladas), bem como balanças digitais, isqueiros utilizados para embalar as porções, rolos e sacos plásticos, os quais eram cortados em pedaços para embalagem, além de mais drogas à granel e outros petrechos (tesouras, prato e colheres com resquícios de drogas). No mesmo sentido são as declarações da testemunha na fase judicial, reiterando a narrativa acima e acrescentando que a investigação durou cerca de dois meses e estava baseada em interceptação telefônica devidamente autorizada. Era a terceira vez que via o acusado deixar os demais corréus no local e sair em seguida. Pelo que apurou o corréu Marcos seria o patrão e os réus Wanderson e Janaína os seus colaboradores. A porta da casa estava aberta e em poucos segundos adentraram na residência, surpreendendo Wanderson fracionando e embalando as drogas. Na residência conversou com o corréu MARCOS e ele informalmente confessou os fatos, inclusive que os demais acusados estavam embalando drogas para ele.

Em igual sentido são as declarações do policial Ricardo Pelisson, confirmando que durante a investigação, inclusive contando com interceptação telefônica, apuraram que Marcos era responsável pelo bando, atuando juntamente com Wanderson, vulgo "Pará" e Janaína. Marcos usava um HB-20 branco e costumava buscar Wanderson e Janaína, levando-os para a residência local dos fatos, sendo que deduziram que local era usado para manusear e fracionar drogas. Assim, no dia dos fatos, Marcos agiu da mesma forma e após deixar o casal no imóvel se dirigiu até uma clínica médica. Uma equipe acompanhou Marcos, ao passo que ele permaneceu perto da casa. Soube que ao ser abordado Marcos prontamente confessou o crime, bem como indicou que o casal estava "trabalhando" no imóvel. Marcos abriu o portão e se depararam com Wanderson e Janaína entre a sala e a cozinha, sentados sobre latas de tinta, fracionando e embalando cocaína. Apreenderam três tijolos e 1856 porções, além de petrechos. Indicou que a casa estava desabitada, sem móveis. Marcos colaborou com os policiais, indicando que a casa era de sua ex-mulher. Apuraram que o entorpecente era usado para "abastecer" o bairro João Paulo II e Marcos usava o veículo HB-20 diariamente.

Desde já saliento que não vislumbro nenhum falso testemunho por parte dos policiais. Como descrito acima a narrativa dos policiais não diverge das imagens captadas na residência onde as drogas foram encontradas. Chegam todos juntos, os

policiais em um carro a frente e logo atrás o réu Marcos em outro veículo. Ademais, o portão é aberto enquanto os carros estão em movimento, logo, qualquer um poderia ter acionado o controle remoto, ressaltando que o acusado Marcos confirmou que autorizou a entrada dos policiais na residência.

Importa esclarecer ainda que algumas contradições existentes nos depoimentos dos policiais em nada os infirma, sendo compreensíveis tais divergências, pois cada um relata o fato da forma como o viu. O contrário sim preocupa, pois somente testemunhas preparadas apresentam versão idêntica para o mesmo fato.

A testemunha Daniela da Silva disse que conhece a acusada Janaína. Não presenciou os fatos, sendo apenas de referência. Confirmou que Janaína trabalhava na cozinha de uma escola, fazia faxinas e cursava faculdade.

A testemunha Isabel Dias asseverou conhece a acusada Janaína. Não presenciou os fatos, sendo apenas de referência. Confirmou que Janaína também fazia faxina para se sustentar.

A testemunha Heliel Santana conhece o acusado Marcos desde abril de 2020. Não presenciou os fatos, sendo apenas de referência.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação.

A materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 63/82 (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e fotos), fls. 338/345, 446/462 e 1074/1095 (laudos periciais) e pela prova oral.

De igual forma a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas restou comprovada, recaindo nas pessoas dos acusados, mormente porque a prova dos autos demonstra que os entorpecentes apreendidos estavam em poder dos acusados e se destinavam ao comércio ilícito, mormente pelas condições da abordagem.

Ressalte-se a confissão policial feita pelo corréu MARCOS, pois a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão e delação feitas na fase extrajudicial possuem eficácia probatória, desde que corroboradas por outras provas colhidas na fase de instrução processual, como é o caso dos autos, mormente quando acompanhado de advogado constituído. Nesse sentido: "Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade" (TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).

Temos ainda a confissão e a delação judicial do corréu WANDERSON, merecendo destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. – 14 ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2003, p. 288). No mesmo caminho segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a

fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso.” (Apelação Criminal 990.09.274150-0 – 14ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi – Data de registro 23/04/2010).

Além do mais, os policiais foram incisivos em afirmar que apenas efetuaram a abordagem porque já vinham investigando os acusados e constataram que de fato atuavam no narcotráfico, usando aquele imóvel para armazenar, fracionar e embalar as drogas. Feita a abordagem de Marcos em outro local, este confessou que atuava no narcotráfico, confirmando que no imóvel mantinha entorpecentes. Retornaram ao imóvel, onde surpreenderam Janaína e Wanderson embalando milhares de porções de cocaína, bem como apreenderam tijolos da droga e demais porções à granel, bem como diversos petrechos, destacando-se as balanças de precisão, instrumento notadamente usado em delitos do tipo.

Ressalto que além da droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a forma como estavam embaladas, a apreensão dos petrechos, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida dos acusados, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente comprometidos com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa aos corréus, que sequer conheciam.

Aliás, como já se decidiu, “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

"Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido" (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de os réus armazenarem e embalarem os entorpecentes apreendidos, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por outro lado, quanto ao delito descrito no artigo 35, "caput", da Lei de Drogas, observo que as provas produzidas não são suficientes para concluir que os acusados estavam associados entre si, reiteradamente ou não, com a finalidade de traficar entorpecentes. Aliás, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes.

No caso, não ficou suficientemente provado que estavam associados para fins de tráfico de drogas. O tipo penal exige "o animus associativo de forma estável e duradora com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo" (STJ - Resp nº 1113728-SC, 5ª T., rel. Felix Fischer, 29.09.2009, v.u.), não bastando a coautoria.

Com efeito, a interceptação telefônica é prova produzida em outro feito e a perícia nos celulares apreendidos, apesar de indicarem a participação dos réus na prática do tráfico de drogas, não comprova a associação para esse fim. Há descrição de uma única conversa entre Marcos e Wanderson, de cujo teor não se pode concluir a prática do crime. Vejamos:

Ademais, embora as imagens do local comprovem que o veículo utilizado pelo réu Marcos adentrou no imóvel no dia anterior, não é possível concluir que estavam nele os demais corréus.

Assim, ante a falta de provas, a absolvição é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero a natureza e a quantidade de droga apreendida (1856 porções de cocaína, pesando 614,59 gramas, 08 porções de cocaína, pesando 354,29 gramas e 03 tijolos de cocaína, pesando 2985,39 gramas).

Na segunda fase, quanto ao corréu MARCOS, não há atenuante ou agravante a ser considerada. Para o corréu Wanderson incide a agravante da reincidência (fls. 107), a qual se compensa com a atenuante da confissão espontânea. Já para a corré JANAÍNA também incide a agravante da reincidência (fls. 105/106), razão pela qual majoro as penas em 1/6 (um sexto), resultando em 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, no mínimo a unidade.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante

da confissão espontânea com a agravante da reincidência" e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Ora, neste caso, os acusados JANAÍNA e WANDERSON ostentam condenações, sendo reincidentes, logo, fica afastada a aplicação do redutor.

Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente.

4. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido" (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu).

Também é descabida a aplicação do redutor para o corréu MARCOS, porquanto comprovado que se dedicava a atividades delituosas.

Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como

“traficante de primeira viagem”, como se pode classificar aquele que possui “estoque” diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo.

A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Pois bem. O caso em tela revela não se tratar de “iniciante”. Com efeito, a par da primariedade, a própria dinâmica fática, envolvendo flagrante policial revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, o acusado deixou pessoas em seu imóvel para embalar drogas, fato que se repetiu no dia anterior, como se viu nas imagens das câmeras de segurança. Ademais, a perícia no celular do réu revelou seu envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 458/461), tudo a confirmar que ele não era iniciante na mercancia ilícita. Ademais, não comprovado que exercia atividade lícita.

Acrescente-se ainda a diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a qual somente é obtida em contato direto com organizações criminosas.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada.

Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Com efeito, os acusados armazenavam, fracionavam e embalavam, para fins de tráfico, frise-se uma vez mais, considerável quantidade de cocaína, substância nociva e de alto poder viciante, e tinham em depósito petrechos, de sorte que a gravidade concreta do delito, revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Não se olvide ainda que os corréus Wanderson e Janaína são reincidentes.

Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo.

Nesse sentido, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICODE ENTORPECENTE. CAUSA DE AUMENTO DO INC. III DO ART. 40 E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, HC 161247/SP, AG.REG. NO HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/02/2019, Órgão Julgador: Segunda Turma, v.u.).

“Ementa: REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MODO MAIS GRAVE JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do modo prisional mais gravoso, consoante vem decidindo esta Corte Superior de Justiça.

2. Na espécie, estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional o estabelecimento do regime mais severo, ante a quantidade do entorpecente. Exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em combinação com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no HC 458375/SC, AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS

2018/0168683-8, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Os réus estão presos. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeram e as penas a que estão submetidos, nesta sentença, são suficientes para retratar suas periculosidades se soltos, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se olvidando que dois deles são reincidentes e o corréu Marcos está em prisão domiciliar. Ademais, como permaneceram presos durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivessem o direito de deixar a prisão.

Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285).

O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançaram o tempo que lhes permitiria a progressão de regime. Ademais, este não é o único requisito e somente ao Juízo das Execuções Criminais cabe analisar o preenchimento dos requisitos legais.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar os acusados:

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa, no mínimo a unidade;
JANAINA APARECIDA NEVES QUEIROZ como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, no mínimo a unidade; e
WANDERSON DA CRUZ BARBOSA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa, no mínimo a unidade;

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Como afirmado acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Sem prejuízo, absolvo-os da acusação de cometimento do crime capitulado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 688).

Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento dos celulares e veículo

apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos e com relação ao veículo basta que seja utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes para a decretação de seu perdimento, como medida desestimuladora da conduta ilícita.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos dos réus (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA